

0001131-02.2021.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001131-02.2021.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001131-02.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165908/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 18590238 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 842/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2165908 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria Cristina de Jesus

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Maria Cristina de Jesus e Emerson Madrini Batista, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, eis que no dia 18 de junho de 2021, por volta das 16 horas, na Praça João Batista Ribeiro de Lima, Vale do Redentor II, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de

desígnios, traziam consigo, nas dependências de recinto onde se realizavam diversões de qualquer natureza, 39 (trinta e nove) porções de crack, pesando 14,96 gramas, 48 (quarenta e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 53,31 gramas, e 10 (dez) porções de maconha, pesando 36,61 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 117/119, veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/114.

Conforme decisão de págs. 152, foi determinado o desmembramento dos autos, prosseguindo-se nestes autos o feito referente a corré Maria Cristina de Jesus.

Manifestou-se o parquet às págs. 169/170, requerendo a prisão preventiva da corré.

Liberdade provisória revogada, conforme decisão de págs. 172/173.

A ré foi notificada (pág. 222) e apresentou defesa preliminar (págs. 229/231), aduzindo em síntese, que portava os ilícitos, mas não praticou tráfico de drogas, e sim, adquiriu para seu próprio uso. Requer a absolvição sumária, bem como reservado o direito de defesa na fase de alegações finais.

A denúncia foi recebida aos 03 de março de 2022 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 232/234). Na oportunidade, manteve-se a prisão preventiva da ré.

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório da acusada, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

O representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A autoria é clara e a materialidade está nas pgs. 187/195 dos autos desmembrados. A ré estava num ponto de tráfico de drogas. Os policiais visualizaram a ré dispensando as drogas. A negativa da ré ficou isolada. Foi flagrada em local de típica venda de entorpecentes e ela tinha a posse de uma quantidade de entorpecentes. Como ela declarou que consome 10 pedras de crack por dia havia com ela quantidade muito maior do que ela alegou consumir por dia. Ela possui maus antecedentes - pgs. 62/63, não sendo cabível qualquer benefício. Requer a fixação do regime fechado, pois foi beneficiada com liberdade provisória e não cumpriu os requisitos impostos.

A defesa, por sua vez, requer a improcedência da ação penal, pois há dúvidas no procedimento policial. Ainda que a ré tenha sido abordada com R\$ 50,00 e algumas drogas, havia uma terceira pessoa no local, o que deixa dúvidas se a droga pertencia a ré. Diante do depoimento da acusada, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o uso.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 11/12), pelo auto de constatação preliminar (págs. 13/14) e exame químico-toxicológico produzido nas pgs. 187/195 dos autos desmembrados (1500204-42.2021.8.26.0613).

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Rivaldo Luciano Tonhão, policial militar, em juízo, narrou que estava em patrulhamento no vale do Redentor e tem uma biqueira muito forte na praça do Vale. Encontraram indivíduos agachados e eles correram. Emerson e Maria Cristina ficaram, mas percebeu ambos arremessando invólucros que foram encontrados e a droga apreendida. Maria Cristina não era suspeita, mas vivia naquele local. Ela frequentava aquele local. Ela negou a posse da droga, embora o depoente tenha visto ela arremessando a droga. Desconhece se a ré é usuária de droga.

Tiago Policcici de Oliveira, policial militar, em juízo, contou que estava em patrulhamento de rotina e nas imediações da praça do Vale do Redentor avistaram a ré e o Emerson agachados. Havia um terceiro indivíduo em pé que correu. A ré dispensou algo e o Emerson também. A ré dispensou o crack e o réu a cocaína e maconha. Ela disse que era usuária de crack e morava por ali num posto de saúde desativado. Não conhecia a ré de outras ocorrências anteriores. Posteriormente avisou a ré, mas não constatou nenhuma traficância da parte dela. Não reconheceu a terceira pessoa que se evadiu quando os policiais chegaram. Pela quantidade de drogas, uma andarilha não teria condições de comprar essa quantidade. Ela deveria estar ali revendendo.

Maria Cristina de Jesus, em seu interrogatório, afirmou que nunca foi presa, nem processada. Tem 46 anos e faz faxina e cata reciclagem. Mora sozinha e usa crack. Nunca foi internada, estava esperando vaga. Usava 10 pedras por dia. Conseguia dinheiro fazendo programas e "metendo o louco" nos velhinhos, fazendo reciclagem e passando roupa. O Emerson é companheiro de usar drogas. Ouviu o que os policiais disseram. Eles chegaram e a depoente tinha R\$ 50,00 e tinha ido comprar droga. Dispensou o baseado de maconha. Os moleques correram. A droga que foi apreendida era do "cara" que saiu correndo. Não conhece ele. Foi a primeira vez que viu essa pessoa.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois "goza de presunção de credibilidade".

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros

indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 39 (trinta e nove) porções de crack, pesando 14,96 gramas, 48 (quarenta e oito) invólucros plásticos contendo

cocaína, pesando 53,31 gramas, e 10 (dez) porções de maconha, pesando 36,61 gramas, para indevidamente "forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoas com as quais não mantêm qualquer desafio ou problema pessoal.

Registre-se que embora a ré tenha dispensado apenas o crack, a menção às demais drogas serve para ratificar o despropósito em cogitar-se que os policiais pudessem ter consigo além das quantidades mencionadas, também a diversidade de drogas apreendidas.

A ré, no entanto, deve ser responsabilizada apenas pela apreensão do crack que dispensou. As demais drogas deveriam ter sido consideradas na conduta do corréu julgado por outro magistrado.

Além disso, o fato de terem sido avistados juntos não basta para que se configure coautoria. Perfeitamente possível que cada qual tivesse consigo as suas próprias drogas para distribuição naquela localidade, conhecido ponto de tráfico de drogas na cidade.

A ré declarou que o corréu não era seu companheiro afetivo. Era apenas conhecido do próprio submundo das drogas. Portanto, não é possível reconhecer cooperação entre ambos que aparentemente apenas foram flagrados na mesma localidade, mas sem que estivessem em franca colaboração.

Por outro lado, em que pese a presunção de inocência e a possibilidade dogmática de incidência do benefício da dúvida é preciso lembrar que o artigo 156 do Código de Processo Penal é categórico no sentido de que "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Inexistente contraprova hábil a desqualificar a prova acusatória, o Juízo deve orientar-se pela verdade processual objetivamente existente no processo, sem margem para decisionismo ou dúvida subjetiva. A dúvida deve estar alicerçada na insuficiência de provas ou na existência de provas com versões conflitantes, antagônicas.

Não é possível externar convicção motivada a partir de ilações particulares do julgador, pois a motivação jurídica decorre do processo de persuasão racional, assim entendido como aquele que pode ser devidamente explicado com base nos elementos presentes no processo e não no âmago psicológico da entidade decidente.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 – destaque do Juízo).

As alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que o fiel da balança incline-se no sentido oposto à pretensão ministerial.

A ré teria dispensado as 39 pedras de crack, quantidade quatro vezes superior àquela que declarou consumir diariamente.

O alegado vício em crack não tem o condão de alterar a imputação.

No que tange à alegada drogadição, é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a

circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figurado viciado-traficante" (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Em suma, o caso sub examen evidencia a prática de crime diverso do simples porte para uso exclusivo e pessoal de entorpecentes. Revela, na verdade, manutenção de drogas para entrega também a terceiros, ficando afastada a possibilidade de desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A denúncia apenas não merece total abrigo no que tange à causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, conforme será melhor analisado na dosimetria.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade dos réus, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de págs. 117/119 para CONDENAR MARIA CRISTINA DE JESUS pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

No que se refere à quantidade de drogas, critério definido no art. 42 da Lei de Drogas, observa-se que a quantidade de drogas dispensada pela ré não passava de poucos gramas de crack, de modo que nada altera a dosimetria.

A ré é primária, pois não há qualquer condenação anotada nas pgs. 62/63. Situação confirmada na FA de pgs. 64.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 no mínimo legal de 5(cinco)

anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa.

Presente, no entanto, a agravante do art. 61, II, "j", Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do Covid-19. A calamidade pública sanitária persistia no país e no Estado de São Paulo e encontrava-se em níveis preocupantes na época dos fatos – junho de 2021.

Há perfeita correlação entre a agravante e a conduta praticada pela ré. O tráfico de drogas ataca exatamente a saúde pública, mesmo bem jurídico que está sendo violentamente prejudicado pela pandemia COVID-19.

Agravo a pena em 1/6, fixando-a em 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes.

Rejeito a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006.

A denúncia situa os fatos na Praça João Batista Ribeiro de Lima. A própria denúncia diz que se trata de conhecido ponto de tráfico de drogas, portanto não é local para qualquer diversão ou espetáculo público. Fato público e notório nesta cidade.

Não se pode emprestar qualquer amplitude ao termo "praça" para confundi-lo com "recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza", pois com apoio léxico tem-se que "recinto é local cercado ou fechado" (Dicionário Aurélio, Ed. Positivo, 3.ed, 2004, vocábulo "recinto" p. 1709).

Ao contrário de "recinto", uma praça é um local geralmente amplo e aberto, bem de uso comum. Aumentar a pena neste caso seria proceder com clara analogia in malam partem.

Há praças de maiores ou menores dimensões espalhadas pelo centro e bairros da cidade. Apenas na parte central são vizinhas e quase contíguas as praças do Epidauro; a praça dos 3 Poderes e a praça Cândido Ribeiro, todas circundadas por escolas nas adjacências.

Assim, o fato de que o réu tenha sido avistado em uma "praça" não autoriza a exasperação de pena na forma pretendida pelo Ministério Público, uma vez que não se trata de "recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza".

A cidade de São José do Rio Pardo é relativamente pequena. Tem cerca de 55.000 habitantes. Existem diversas praças, escolas, locais de atendimento público espalhados pela urbe, de modo que encampar a tese ministerial também ocasionaria que em praticamente todos os tráficos de entorpecentes nesta cidade ensejassem a incidência da majorante em verdadeira e inaceitável aplicação de responsabilidade penal objetiva, violando o finalismo penal. Estariam livres apenas, em tese, traficantes que se utilizassem da zona rural.

Some-se a isso o fato da infração ter se consumado durante a pandemia da Covid-19 (a pena foi agravada por isso), momento em que, dadas as regras de restrição à circulação social, não é possível se presumir que uma praça, por si só, seja um local de maior aglomeração de pessoas.

O mesmo entendimento prevaleceu perante a 11ª Câmara de Direito Criminal em voto de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Paiva Coutinho na apelação

criminal 0000713-69.2018.8.26.0575 desta mesma vara, julgada aos 04.03.2021.

A ré faz jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois primária e a quantidade de entorpecentes era pequena.

Assim, diminuo a pena em 2/3 fixando-a em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Donde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 509.578/SP (2019/0133777-0), STJ, Rel. Antônio Saldanha Palheiro DJe 16.05.2019. Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

Em caso análogo, ao apreciar a apelação nº. 0000032-53.2016.8.26.0613, a Colenda 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória proferida por este Juízo, mantendo igualmente a determinação de que o réu inicie o cumprimento da pena sob o regime aberto.

Também a 12ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação nº 0000322-85.2016.8.26.0575 desta comarca manteve o regime inicial aberto com expressa alusão às Súmulas 718 do STF e Súmula 440 do STJ, bem como ao HC STF nº 118.533.

A 16ª Câmara Criminal seguiu o mesmo norte na Apelação nº 0001003-55.2016.8.26.0575 desta Comarca, em acórdão da Relatoria do Eminentíssimo Desembargador Guilherme de Souza Nucci.

Para melhor ilustrar:

TJSP-) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PROFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM DESFAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PACIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DA TESE NO SENTIDO DA NÃO HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS, SE PRIVILEGIADO NOS MOLDES DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME ABERTO ESCOLHIDO PELO JUÍZO EM COERÊNCIA À QUANTIDADE DE PENA (01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO), PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO AGENTE E DEMAIS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO APELO. (Apelação nº 0002209-93.2017.8.26.0438, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Diniz Fernando. j. 12.11.2018, Publ. 22.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM COMPROVAM A DESTINAÇÃO DO TÓXICO À MERCANCIA E NÃO AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO ACERTADA. QUANTIDADE DAS DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO RÉU QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E HEDIONDEZ DO CHAMADO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE FOI AFASTADA PELO PLENO DO E. STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E OUTRA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação nº 0000109-82.2018.8.26.0616, 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Francisco Bruno. j. 08.11.2018, Publ. 12.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - CONFIGURAÇÃO - DIMINUIÇÃO DO ACRÉSCIMO. PRIVILÉGIO - SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - MERA ILAÇÃO - QUANTIDADE POUCA EXPRESSIVA DE MACONHA - NEGATIVA INFUNDADA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS - CRITÉRIO - ART. 42 DO MESMO DIPLOMA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO - HEDIONDEZ AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS Nº 118.533. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. (Apelação nº 0003964-83.2015.8.26.0322, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Vico Mañas. j. 05.12.2018, Publ. 07.12.2018).

TJSP-) HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME PRISIONAL FECHADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ADMISSIBILIDADE - SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A MOTIVAÇÃO DA R. SENTENÇA, PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, NÃO SÓ PORQUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECLAROU A - INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL DISPOSITIVO, MAS TAMBÉM PORQUE O PRETÓRIO EXCELSO, NO HABEAS CORPUS Nº 118533/MS, AFASTOU A NATUREZA HEDIONDA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". ALIÁS, HÁ ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO, ACERCA DA NÃO HEDIONDEZ DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO", SEGUIDA POR ESTA COLENDIA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE EFEITO ERGA OMNES OU VINCULANTE DO R. DECISUM DAQUELA CORTE CONSTITUCIONAL, É DE BOM ALVITRE QUE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IGUALDADE, O ENTENDIMENTO EXTERNADO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 118.533 SEJA ADOTADO POR TODOS OS JUÍZES E TRIBUNAIS BRASILEIROS, EVITANDO-SE, COM ISSO, DECISÕES EM SENTIDOS OPOSTOS ACERCA DA MESMA MATÉRIA E QUE SOMENTE AQUELES ACUSADOS QUE POSSUAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA GALGAR TODAS AS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO SEJAM BENEFICIADOS PELOS EFEITOS DECORRENTES DA NOVA ORIENTAÇÃO DE QUE O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO POSSUI CARÁTER HEDIONDO. DE RESTO, CABÍVEL, EXCEPCIONALMENTE, O REGIME ABERTO EM FACE DO QUANTUM DA PENA E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus nº 2215577-73.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Moreira da Silva. j. 25.10.2018, Publ. 30.10.2018).

TJSP-) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - INDEFERIMENTO - CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - CÁLCULO QUE CONSIDEROU A HEDIONDEZ DO CRIME - INADMISSIBILIDADE - RECENTE JULGAMENTO DO STF QUE ENTENDEU NÃO SER HEDIONDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - HC 118533 - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DO STF - SÚMULA 512 DO STJ CANCELADA - NATUREZA HEDIONDA AFASTADA - CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DETENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - AGRAVO PROVIDO. (Agravado de Execução Penal nº 0013382-10.2018.8.26.0041, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Newton Neves. j. 09.11.2018, Publ. 09.11.2018).

O regime deve ser o ABERTO, diante dos precedentes supra, bem como levando em conta a primariedade da ré, a pena inferior a 4 anos e a detração.

Inviável a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 - SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 - SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que "se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa - e com maior razão."

Para este Juízo não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestarem serviços comunitários.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

Com efeito, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

Por fim, a ré não dispõe de senso de responsabilidade suficiente para qualquer medida alternativa. Verificou-se no curso do processo que descumpriu as condições da liberdade provisória.

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's, ficando suspensa a cobrança na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c.c art. 3º do CPP, pois defiro-lhe à ré, patrocinada por advogado dativo, os benefícios da AJG.

Honorários na forma do convênio OAB-DPE. Expeça-se certidão.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão no regime aberto, facultando-se à ré apresentar-se em Juízo nos dias úteis das 13:00 às 16:30 para que sua audiência admonitória seja "encaixada" na pauta regular, prevenindo a intervenção da polícia para o cumprimento do mandado de prisão;

Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

Diante da pena imposta, bem como regime fixado, REVOGO a prisão preventiva da ré, conforme orientação que dimana do princípio da homogeneidade. Expeça-se alvará de soltura.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA